

1500080-02.2020.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/09/2022

... 5. Dosimetria. Redução da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a "quantidade de drogas" como circunstância especial negativa. Redução do acréscimo aplicado na segunda fase do cômputo das penas do crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. 6. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. Réu que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500080-02.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500080-02.2020.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALDO CORNIA NETO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

ALDO CORNIA NETO, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, FRANCISCO LAURENTINO PEREIRA, ALINE PEREIRA FURTADO e FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, vulgo "Nando Gordão", qualificados nos autos, foram denunciados e regularmente processados como incurso no artigo 180, §1º, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, porque, em data, horário e local indeterminados, porém pouco antes de 07 de janeiro de 2020, na cidade de Iracemápolis, comarca de Limeira, integraram e promoveram, pessoalmente, organização criminosa, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente

ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4(quatro) anos, dentre elas o de receptação qualificada, a seguir descrito.

Consta ainda que, na data de 07 de janeiro de 2020, por volta das 12h00min, na Rua Luís Raetano, nº 108, na cidade de Iracemápolis, comarca de Limeira, ALDO CORNIA NETO, LUCIANO DE ASSIS FEITOSA, LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA, FRANCISCO LAURENTINO PEREIRA, ALINE PEREIRA FURTADO e FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, já qualificados, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão material de atos visando ao resultado comum, adquiriram, receberam, tinham em depósito e ocultaram, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam e deviam saber ser produtos de crime, consistentes na carga de 42.711 (quarenta e dois mil, setecentos e onze) litros de óleo diesel, avaliada em R\$ 135.590,301, pertencente à empresa Tobras Distribuidora de Combustíveis Ltda.2, um caminhão IVECO/STRALISHD, branco, placas IOW20753, avaliado em aproximadamente R\$ 70.000,004, pertencente a Eduardo Sokolenko, e dois semirreboques SR/GUERRA, brancos, placas CSK5506 e CSK55075, avaliados no total em aproximadamente R\$ 80.000,006, pertencentes a empresa FFMJ Locação e Serviços de Transportes Eireli7, que haviam sido roubados anteriormente.

Foi autorizada judicialmente a quebra de sigilo de dados e aplicativos dos aparelhos celulares apreendidos com os réus (fls. 551/552), cujos documentos estão acostados a fls. 925/2000, 2215/3366 e 3387/5304, e o relatório de investigação a fls. 2040/2118.

Recebida a denúncia pela r. decisão de fls. 574/575. A Folha de antecedentes e certidões criminais dos acusados foram juntadas (fls. 690/735).

A ré ALINE foi citada a fls. 5550 e apresentou resposta escrita (fls. 872/874). O acusado LUCIANO foi pessoalmente citado (fls. 916) e apresentou resposta à acusação (fls. 5660/5667). ALDO foi citado a fls. 5451, mas ainda não ofertou resposta à acusação e, intimado sobre tal fato, declinou que possui advogado constituído (fls. 5740). Após decisão judicial (fls. 5753), a Defensoria foi intimada e apresentou resposta à acusação em relação ao mencionado réu (fls. 5757/5758). Já LUIZ foi citado (fls. 5373), apresentou resposta à acusação (fls. 5340/5342). O réu FRANCISCO também foi citado (fls. 5336) e apresentou resposta escrita (fls. 5338/5339).

Por fim, o acusado FERNANDO foi citado (fls. 5454) e apresentou resposta escrita (fls. 5461/5464).

Pela z. serventia, foi elaborada a Planilha de fls. 5767/5768 constando o relatório do processo.

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 5764/5766).

Como o advogado constituído de LUCIANO DE ASSIS FEITOSA não compareceu na primeira audiência de instrução, o processo foi desmembrado (Feito nº 0002623-81.2022.8.26.0320), com aplicação de multa (fls. 5.895).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, cinco testemunhas arroladas pela acusação e interrogados os réus (mídia).

O Ministério Público, entendendo provados os fatos, pugnou pela procedência do pedido condenatório nos exatos termos da denúncia. Discorreu sobre a pena e o regime cabíveis a cada acusado (fls. 6013/6030).

A Defesa da acusada ALINE PEREIRA FURTADO, por seu turno, sustenta a fragilidade das provas obtidas no curso das investigações, requerendo a absolvição (fls. 6036/6045).

A Defesa dos acusado FERNANDO ROBERTO DE SOUZA, de outra sorte, preliminarmente requereu a nulidade pela ilicitude da quebra do sigilo das comunicações, ante a ausência de fundamentação. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, por manifesta insuficiência de provas para a condenação, e subsidiariamente, a desclassificação para a receptação na modalidade simples, além do reconhecimento de associação criminosa, conforme tipo previsto no artigo 288 do Código Penal (fls. 6046/6065).

A Defesa do acusado ALDO CORNIA NETO requereu, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida por atuação indevida de agente integrante da guarda municipal; a nulidade do flagrante, em decorrência de buscas realizadas com nítida violação de domicílio, sem amparo em mandado judicial; a inadmissibilidade das provas obtidas por quebra de sigilo, ante a ausência de fundamentação da decisão que autorizou tal providência; ausência de degravação do teor integral das conversas interceptadas; no mérito, pleiteia a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 6067/6086).

A Defesa de LUIZ PAULO LAURENTINO PEREIRA e FRANCISCO LAURENTINO, por derradeiro, sustentou a nulidade das provas decorrentes das interceptações telemáticas, ante a ausência de fundamentação da decisão que autorizou tal providência; no mérito, sustenta a insuficiência probatória para condenação (6092/6096).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia trazida aos autos, passo ao exame das preliminares sustentadas pelos doutos Defensores.

1 - Da nulidade da prova produzida por intermédio da quebra de sigilo telefônico, em razão da ausência de fundamentação da decisão que autorizou tal providência.

O argumento relativo à deficiência da fundamentação que autorizou a quebra do sigilo telefônico não merece acolhimento, pois a decisão de fls. 551/552, embora sucinta, sustenta-se em relatório extremamente minucioso e fundamentado, conforme se observa do documento de fls. 543/548, que expõe de forma clara a

imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, sendo plenamente válida a utilização da técnica "per relationem", como se observa do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - COMPATIBILIDADE DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, IX) - CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO RECURSO DE AGRAVO - PRECEDENTES - ATO DECISÓRIO INSUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 622/STF) - RECURSO NÃO CONHECIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender incabíveis embargos de declaração contra decisões monocráticas proferidas por Juiz da Suprema Corte, deles tem conhecido, quando inócua hipótese de omissão, obscuridade ou contradição, como recurso de agravo. Precedentes. - Não cabe recurso de agravo contra decisão do Relator, que, motivadamente, defere ou indefere pedido de medida liminar formulado em sede de mandado de segurança impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Revela-se legítima, e plenamente compatível com a exigência imposta pelo art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a utilização, por magistrados, da técnica da motivação "per relationem", que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, pelo Ministério Público ou por autoridades públicas, cujo teor indique os fundamentos de fato e/ou de direito que justifiquem a decisão emanada do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 25.936-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2009) (negritei).

2- Da necessidade de degravação integral do conteúdo das mensagens

Conforme entendimento prevalente, o fato de não ter sido realizada a transcrição integral das mensagens interceptadas não ofende o princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, da CF).

Com efeito, as Cortes Superiores já pacificaram entendimento no sentido de ser prescindível a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas, ou, como no caso, das mensagens captadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, assim como disponibilizada a totalidade do material que, direta e indiretamente, àquele se refira:

“É assente no Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido da desnecessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Dessarte, suficiente a entrega da totalidade dos áudios captados à defesa, portanto não há se falar em nulidade no caso dos autos” (HC 422.642/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 25.09.2018, DJe 02.10.2018).

Os trechos com interesse para a lide penal foram transcritos pelas autoridades policiais, foram carreados aos autos, e a eles os doutos Defensores tiveram pleno acesso.

3 - Da atuação da guarda municipal

No tocante à preliminar de nulidade, em relação à participação de guardas municipais na ação que ensejou as prisões em flagrante, tem-se que suas atuações foram perfeitamente válidas, até porque, no caso, os agentes apenas prestaram apoio às polícias civil e militar, sendo despropositado buscar o reconhecimento de nulidade numa ação conjunta de instituições, visando garantir a ordem.

É cediço que o artigo 144, §8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito, o que, inequivocamente, é a hipótese dos autos.

Para ilustrar:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal. 2. Recurso improvido". (RHC 20.714/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJ 4/8/08)

No mais, como já asseverado, a ação da guarda municipal, no caso em tela, foi apenas de apoio, sendo sua atividade meramente coadjuvante, e seria despropositado entender que as instituições de segurança do Estado não pudessem prestar suporte recíproco.

4 - Da ilicitude do ingresso dos policiais no imóvel, ante a ausência de mandado judicial.

Por fim, sustenta-se a ilicitude das provas obtidas, em virtude de busca domiciliar não amparada constitucionalmente.

Respeitado o entendimento defensivo, e especialmente consideradas as circunstâncias do caso em concreto, pois tal análise merece apreciação casuística, tal argumento não merece ser acolhido.

Considerado o conjunto probatório, não há que se falar em nulidade do flagrante por violação de domicílio, pois conforme demonstrado nos autos, os policiais obtiveram informação de que um caminhão havia desviado de sua rota, por intermédio de sistema de rastreamento, foram ao local e puderam visualizar, sobre o muro do terreno onde o bem estava localizado, uma movimentação estranha, com a utilização de mangueira para se transferir combustível de um automóvel para outro.

Portanto, consideradas circunstâncias concretas peculiares, vigentes estavam as fundadas razões justificadoras do ingresso no imóvel, ante a patente situação de flagrância, uma das exceções à inviolabilidade constitucionalmente prevista.

Evidentemente, o comando contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal não configura direito absoluto, mas de outra parte, não se nega a imprescindibilidade de justa causa para a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar. Quer dizer, a situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas antes de qualquer ingresso em domicílio, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas, sacrificando-se a garantia constitucional.

Exige-se que os elementos fáticos anteriores ao ingresso no domicílio permitam inferir, com o mínimo de razoabilidade, a situação de flagrante a excepcionar a exigência de prévia ordem judicial.

Na situação em concreto, os fatos como descritos configuraram quadro de justa causa para o ingresso na moradia acusado, tendo em vista que, no momento da ação policial, elevada era a probabilidade do estado de flagrante delito.

Ao final, com a apreensão do caminhão subtraído, constatação in loco dos atos de transferência de combustível, e identificação dos respectivos instrumentos utilizados (bombas e mangueiras), restou comprovado o estado flagrancial que legitimou a ação policial.

Neste sentido, aliás, traz-se julgado recente de situação bastante similar, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Recurso da defesa. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. Preliminar de ilicitude das provas colhidas diante de violação de domicílio. Alegação de inexistência de situação de flagrância ou mesmo de ordem judicial autorizadora do ingresso na residência. Pleito absolutório. Pleito subsidiário de redução das penas. 1. Preliminar de nulidade. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 2. O ingresso regular na casa alheia depende da existência de justa causa para a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas, sacrificando-se a garantia constitucional. 3. Ação policial que foi precedida pela abordagem de um indivíduo que tinha acabado de sair da casa do réu, o qual portava uma porção de maconha e informou aos policiais que o réu lhe tinha dado aquela droga, bem como que possuía mais drogas dentro da casa. Réu que foi visto no quintal da casa com uma sacola nas mãos sendo que correu, abruptamente, para o interior da moradia ao notar a presença dos policiais. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio que está amparado pelo permissivo constitucional. Preliminar de nulidade das provas. Afastamento. 4. Mérito. Condenação adequada. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas, pelo exame químico-toxicológico, pela apreensão de arma de fogo e pela respectiva prova pericial que atestou sua potencialidade lesiva. Autoria certa. Depoimentos firmes dos policiais militares confirmando a prisão em flagrante do acusado, bem como o encontro das substâncias entorpecentes e de uma arma de fogo, no interior de sua residência. 5. Dosimetria. Redução da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a

"quantidade de drogas" como circunstância especial negativa. Redução do acréscimo aplicado na segunda fase do cômputo das penas do crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo. 6. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. 7. Regime fechado estabelecido em razão da reincidência e dos maus antecedentes. 8. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500728-06.2020.8.26.0603; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2022; Data de Registro: 27/07/2022) (negritei)

Assim, rejeitada a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 08/09), boletins de ocorrência (fls. 35/44, 424/425, 526/528, 529/531, 532/537 e 538/541), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 47/50 e 51), pelas notas fiscais de fls. 52/53, pelos documentos de fls. 54/56 e 512/525, pelos autos de entrega (fls. 67/71), pelo auto de avaliação (fls. 422/423), documentos de rastreamento de veículos (fls. 433/508), laudos periciais de exame em local (fls. 2014/2020) e dos veículos apreendidos (caminhão trator, Mercedes-Benz, modelo 1938S, cor vermelha, placas BXF-0990- fls. 2021/2025; semirreboque, marca Reb/Gotti, modelo SRTQL2E 095D, cor branca, placas CNR-0864 - fls. 2026/2030; semirreboque, marca Reb/Gotti, modelo SRTQL2E 092, cor branca, placas CNR-0865- fls. 2026/2036; - fls. 2031/2036), documentos de fls. 925/2000, 2215/3366 e 3387/5304 (relativos à quebra de sigilo de dados), pelo relatório de investigação nº 11/2020 de fls. 2040/2118, detalhando a quebra de sigilo de dados, e pela prova oral.

Cabe apreciar o teor dos depoimentos e das provas documentais produzidas sob o crivo do contraditório, para se reconhecer ou não as autorias delitivas.

FRANCISCO e ALDO, em sede policial, assumiram a aquisição de carga de combustíveis, mas asseveraram que não sabiam de sua origem ilícita (fls. 18/19 e 26/27).

FERNANDO, também ouvido em interrogatório policial, disse que estava acompanhando ALDO, mas não sabia da procedência dos veículos e do combustível (fls. 20/21).

LUIZ PAULO, também na delegacia, afirmou que estava no local por acaso, conversando com seu irmão FRANCISCO, ressaltando que não tinha conhecimento de qualquer carga de procedência ilícita no local (fls. 22/23).

ALINE, de outra senda, negou qualquer participação no ilícito, consignando que apenas estava na companhia de seu amásio FERNANDO (fls. 28).

Em juízo, ALDO preferiu ficar em silêncio, tendo FERNANDO seguido a mesma estratégia (mídia).

LUIZ PAULO por sua vez, consignou ter ido ao local apenas estacionar seu caminhão. Justificou a tentativa de se desfazer do celular, ao argumento de que mantinha conversas inapropriadas com sua esposa. Confirmou ser irmão de Francisco, mas negou ter tentado evadir-se no momento em que a polícia chegou. Salientou que outras

pessoas realmente estavam retirando o combustível de um veículo para outro, mas não as conhece (mídia).

FRANCISCO reiterou o depoimento apresentado na fase policial, tendo aduzido que ALDO ofereceu-lhe o combustível, após receber oferta de terceiro. Alegou ter comprado a carga desconhecendo sua origem era ilícita, com pagamento a ser realizado posteriormente. Argumentou que existia nota fiscal. Disse que tentou fugir por ter ouvido disparos de arma de fogo. Disse, ainda, que o combustível foi transferido para o caminhão de LUCIANO. Em relação às demais perguntas, optou pelo direito ao silêncio (mídia).

ALINE, ouvida em juízo, disse que à época dos fatos era companheira FERNANDO, confirmando o apelido "Nando Gordão". Teria ido ao local no veículo VW GOL, juntamente com ALDO e FERNANDO, de Araras até Iracemápolis, com o propósito de passar no supermercado em seguida, e realizar as compras domésticas mensais. Negou ludibriado os policiais, pois não tinha conhecimento de atividade ilícita desenvolvida por seu companheiro (mídia).

Por sua vez, o representante da transportadora vítima Fernando José Moscatello contou que é administrador da empresa "FFMJ Locação e Serviços de Transportes EIRELI", esclarecendo que Eduardo Sokolenko presta serviços para a empresa. Contou que Eduardo estava transportando uma carga de diesel S10 da cidade de Santos até Ribeirão Preto, utilizando um caminhão Iveco de sua propriedade e dois semirreboques Guerra, pertencentes à transportadora. Afirmou que, no final da manhã, recebeu a informação da empresa de rastreamento CELIG de que o caminhão havia saído da rota e estaria no município de Iracemápolis. Narrou que, logo em seguida, soube que policiais da cidade haviam encontrado os veículos e a carga. Disse que a esposa de Eduardo lhe telefonou avisando que ele havia sido libertado na cidade de Monte Mor, após ser vítima de um roubo na Rodovia Anhanguera, próximo à cidade de Araras. Informou que a carga está avaliada em R\$135.590,30, o conjunto de semirreboque em R\$80.000,00 e o caminhão em R\$70.000,00 (mídia e fls. 17 e 5894).

Já a vítima Eduardo Sokolenko asseverou ser motorista de caminhão e explicou que é proprietário do caminhão Iveco, placas IOW 2075/São Paulo, sendo os semireboques, placas CSK 5506 e CSK 5507, de propriedade da transportadora FFMJ, para qual prestou serviços. Narrou transportava uma carga de óleo diesel S10, na quantidade de 42.711 litros, de Santos para Ribeirão Preto, quando, próximo à cidade de Araras foi interpelado por um veículo VW/Gol, com duas pessoas dentro, que o roubaram mediante uso de arma de fogo. Asseverou que os roubadores o obrigaram a estacionar o caminhão na rodovia e entrar no carro, subtraindo o caminhão e a carga. Disse que, após algumas horas, os bandidos o libertaram na Rodovia SP101, na cidade de Monte Mor. Contou que foi até uma lanchonete e telefonou para sua esposa, a qual entrou em contato com o Fernando, funcionário da transportadora, que o resgatou e levou até a delegacia. Não reconheceu nenhum dos réus como autores do roubo, tampouco o veículo VW/Gol apreendido nos autos (mídia - fls. 5894).

O Delegado de Polícia Dr. Rodrigo Rodrigues explicou como ocorreram as investigações desde as prisões dos acusados, as quais demonstraram a existência de organização criminosa, que atuava de maneira habitual e profissional. Destacou como foi a abordagem da acusada Aline no interior do veículo VW/Gol tentando se esconder no primeiro momento e, após sua abordagem, alegando que esperava seu namorado Fernando, apontando uma empresa próxima, mas falsamente indicada. Relatou que, ao ser novamente questionada, Aline disse que não sabia. Informou individualmente a

conduta de cada acusado no dia das prisões: os irmãos Francisco e Luiz Paulo tentando fugir para os fundos do terreno ao perceberem a chegada dos policiais; Aldo e Luiz Paulo tentando se esconder ao serem surpreendidos fazendo o transbordo do combustível, chegando Luiz Paulo a jogar seu celular para o outro lado do muro antes de ser detido. Disse que Francisco, também, tentou esconder seu aparelho celular nos fundos. Destacou, ainda, que Fernando só foi encontrado após a chegada da perícia, estando escondido embaixo do caminhão roubado, vindo a ser identificado como o proprietário do outro caminhão que recebia a carga. Confirmou a existência de aparelho bloqueador no interior da cabine do veículo roubado. Informou que Francisco locou o imóvel, sendo juntado aos autos o contrato. Destacou o teor da transcrição dos áudios e gravações referente a quebra dos sigilos, sendo Francisco responsável por receber e negociar a carga, Luiz Paulo fazia a transferência da carga. Relatou que Aldo, Fernando e Aline chegaram juntos ao local, inclusive foi comprovado por uma foto que estava em um dos aparelhos, juntada aos autos. Afirmou que Aldo chegou a trocar mensagens específicas em relação ao roubo, recordando-se de parte de seu teor. Relatou que o caminho do veículo roubado e do veículo Gol foram desvendados, destacando a relação dos integrantes da organização criminosa e seus antecedentes, tudo conforme detalhado nos relatórios de investigação juntados aos autos (mídia - fls. 5894).

Da mesma forma, o investigador de polícia Luís Antônio Souza esclareceu os trabalhos investigativos. Afirmou que recebeu informações de uma empresa de monitoramento sobre um caminhão e carretas, com carga de combustível, que foi desviado da rota e estaria na Rua Luiz Raetano, município de Iracemápolis. Em razão disso, dirigiu-se ao local e avistou um veículo VW/Gol estacionado defronte o endereço, com a acusada ALINE no banco de passageiro. Questionada, ela afirmou que estava aguardando o companheiro, mas não indicou sua localização, ofertando respostas desencontradas. Narrou que o local onde o rastreador indicava a localização do caminhão tratava-se de um imóvel murado e com portões fechados, sendo que integrantes da equipe subiram no muro e avistaram dois caminhões, sendo transbordados a carga de um deles para o outro. Disse que havia alguns homens em volta dos caminhões e, após a polícia dar ordem de parada, eles tentaram fugir, mas foram abordados pela equipe. Asseverou que o caminhão estava ligado e as bombas conectadas às mangueiras, fazendo o transbordo do combustível diesel, e, além disso, na cabine do caminhão havia um aparelho bloqueador de sinal de rastreamento. Narrou que, em seguida, um dos réus (LUCIANO) foi encontrado escondido embaixo da carreta do caminhão subtraído (mídia).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Guilherme Augusto Cavichia, acrescentando que, ao chegar no local dos fatos, a acusada ALINE tentou esconder-se no interior do veículo, encostando o banco. Narrou, ainda, que a ré afirmou estar aguardando o marido/namorado, que estaria trabalhando na empresa ao lado, mas depois informou que ele havia entrado em uma garagem, sem revelar qual (mídia - fls. 5894).

Por derradeiro, a testemunha Leandro Mezzini Batista (guarda civil do município de Iracemápolis), relatou que recebeu informações da empresa de monitoramento CELIG sobre um veículo com carga de combustível que fora desviado da rota original e estaria na cidade de Iracemápolis, na Rua Luiz Raetano. Narrou que rumou até o local e subiu no muro do imóvel, sendo possível visualizar dois caminhões bitrem com a mangueira acoplada em cima dos tanques e fazendo transbordo do conteúdo de um para outro caminhão. Disse ter visto o réu LUIZ PAULO manuseando a mangueira de um dos caminhões. Em razão disso, deu ordem de parada ao referido réu, mas ele tentou empreender fuga, junto com FRANCISCO, contudo, ambos foram abordados. Afirmou que mais indivíduos foram abordados pela equipe. Explicou que, posteriormente, abordou LUCIANO, que estava escondido embaixo de uma carreta. Relatou que no local foram

encontrados bombas que estavam fazendo o transbordo da carga e lacres rompidos das saídas do caminhão subtraído. A respeito da ré ALINE, esclareceu que ela foi abordada fora do imóvel, dentro de um veículo VW/GOL, e afirmou estar aguardando seu namorado que trabalhava em uma empresa ao lado, diverso do imóvel utilizado como garagem pela organização criminosa (mídia - fls. 5894). No mesmo sentido os relatos do guarda civil do município de Iracemápolis Osmar Verati (mídia - fls. 5894).

Analisando-se todos os depoimentos, bem como o arcabouço documental amealhado, especialmente por intermédio das interceptações de conversas mantidas por aplicativos de diálogos nos aparelhos celulares apreendidos, tem-se que o delito de receptação qualificada está inequivocamente demonstrado com relação aos acusados LUIZ PAULO, FRANCISCO, FERNANDO e ALDO, havendo dúvida, não obstante, com relação à corré ALINE.

Pois bem, conforme foi possível verificar, a ação policial iniciou-se porque houve "falha" dos bandidos responsáveis pelo roubo do caminhão, que não desativaram por completo o sistema de rastreamento de veículos, bloqueando apenas a cabine, mas permitindo que os dispositivos das carretas permanecessem ativos. A partir daí, foi possível que a polícia civil, acionada, pudesse localizar o automóvel, e dar início às buscas, primeiramente encontrando a acusada Aline no interior de um veículo Gol estacionado nas imediações, e depois, constatando, sobre o muro de um imóvel, os cinco acusados remanescentes (o corréu Luciano responde à acusação em autos desmembrados), realizando, cada um, de acordo com as respectivas atribuições, a transferência do combustível que era transportado pelo caminhão roubado, para outro veículo.

Os acusados LUIZ PAULO, FRANCISCO, FERNANDO e ALDO estavam no imóvel e ao verificarem a presença policial, tentaram fugir, bem como ocultar os aparelhos telefônicos, que continham mensagens incriminadoras, como foi possível verificar nas conversas interceptadas.

FRANCISCO era o detentor do terreno palco da prisão em flagrante, onde realizada a transferência da carga roubada, e embora tenha afirmado que alugou o imóvel com o único propósito de utiliza-lo como um estacionamento, ao que tudo indica tratava-se um ponto de receptação de carga. No mais, a alegação de que havia adquirido o combustível sem saber de sua origem ilícita revela uma ingenuidade absolutamente incompatível com a realidade, tratando-se de versão, no mínimo, pueril.

ALDO, que em juízo manteve-se em silêncio, também havia apresentado na fase policial a versão de que não tinha conhecimento da origem ilícita dos combustíveis, consignando que teria recebido a oferta de um sujeito de nome "Pedro", repassando a proposta ao corréu FRANCISCO. Tal narrativa é fantasiosa e despropositada, sendo certo que a negociação de carga de combustíveis não se trata de prática simples, não se comparando, por exemplo, à simples aquisição de um aparelho celular ou uma bicicleta, sendo evidente a mendacidade do acusado.

FERNANDO, apesar de afirmar não ter envolvimento com os fatos, reforçando que apenas foi ao local para dar uma carona ao co-acusado ALDO, tal narrativa não ostenta verossimilhança, especialmente pela circunstância de ter sido identificado como "Nando Gordão" (apelido confirmado pela sua ex-companheira Aline), pessoa envolvida em negociatas suspeitas, conforme registros de conversas. Ademais, como verificado nas imagens captadas (fls. 2062/2063), foi possível constatar que o

acusado manuseava as mangueiras utilizadas para transferir os combustíveis entre veículos, o que afasta o argumento de que não tinha conhecimento dos fatos.

LUIZ PAULO, irmão do corréu FRANCISCO, apesar de negar a participação no evento criminoso, asseverando que estava no local apenas para guardar seu caminhão, não tendo relação alguma com a aquisição de carga roubada, também foi desmentido pelas imagens, sendo identificado no ato de manusear as mangueiras usadas na retirada do combustível, consoante imagem de fl. 2062.

Sobre o delito de receptação dolosa na forma qualificada, por ostentar como elemento subjetivo do tipo o conhecimento prévio da origem espúria do bem obtido, pode ser provado plenamente pelas circunstâncias e elementos exteriores que permitam deduzir tal circunstância.

Evidentemente, este conhecimento prévio da origem delituosa do bem recebido, caso tivesse de ser provado de forma direta e inequívoca, consubstanciar-se-ia em prova diabólica, e portanto, impossível de ser produzida, exceto pela confissão. Isso porque, este conhecimento prévio da origem do bem é questão íntima que não se revela exteriormente de maneira inconteste.

Há sempre a possibilidade de se afirmar que não se sabia da origem do bem, circunstância que, levada às últimas consequências, levaria sempre à absolvição pela ausência de dolo.

Nesse sentido, prevalece o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECEPTAÇÃO. Materialidade e autoria comprovadas. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Condenação mantida. Penas dosadas sem excessos. Apelo defensivo desprovido. (TJ-SP - APR: 00007301320178260617 SP0000730-13.2017.8.26.0617, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 22/09/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/09/2020). "Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição" (TACRIM-SP- Ap. - Rel. Carlos Biasotti - j. 05.12.1996 - RJTACrim 34/235). negritei

Cabe ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais civis, militares e guardas municipais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Nesse sentido, prevalece o seguinte entendimento:

Receptação. Preliminar. Nulidade da sentença. Não ocorrência. Sentença fundamentada na ciência da origem ilícita do bem rechaçando o pedido de desclassificação para receptação culposa. Preliminar afastada. Mérito. Materialidade e autoria

confirmadas. Validade de declarações de policiais. Circunstâncias que fazem presumir a ciência da ré acerca da origem ilícita do bem. Condenação acertada. Pena e regime adequados. Impossibilidade da fixação da pena de multa isolada por falta de previsão legal. Pena que não pode vir aquém do mínimo pela menoridade relativa. Súmula 231, STJ. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00005942020178260551 SP0000594-20.2017.8.26.0551, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 23/01/2020, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020) negritei

Pelos que deflui dos autos, portanto, é absolutamente inequívoco que os acusados LUIZ PAULO, FRANCISCO, ALDO e FERNANDO participaram de esquema direcionado à receptação de combustíveis transportados em caminhões, e obtidos de maneira ilícita, sendo de rigor a condenação pelo crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, observando-se a forma qualificada pelo evidente caráter comercial da empreitada, ante a quantidade e valor expressivos da mercadoria.

Com relação a ALINE, merece a absolvição, pois embora tivesse ido ao local na companhia do réu ALDO e de seu amásio e corréu FERNANDO, e estivesse aguardando de maneira suspeita no interior do veículo GOL estacionado nas imediações, inclusive com indicativos de que tenha acobertado a ação criminosa por ocasião da chegada dos policiais, não há como se afirmar, com a devida segurança, que estivesse mancomunada com os demais agentes do crime, devendo a situação de dúvida ser solucionada na maneira que lhe é mais favorável.

Assim, ante a conclusão inequívoca do envolvimento dos réus, exceto ALINE, no delito de receptação qualificada, cabe apreciar a acusação pertinente ao crime de participação em organização criminosa, sendo necessário, primeiramente, a análise do conceito legal previsto pela Lei n. 12.850/2013, in verbis:

Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

§ 2º Esta Lei se aplica também:

I - às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

II - às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território nacional.

II - às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. (Redação dada pela lei nº 13.260, de 2016)

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.

§ 3º A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização.

Pelo conceito legal supracitado, exige-se, para a configuração da organização criminosa, que quatro ou mais pessoas se unam com propósitos bem definidos e divisão ordenada de tarefas, de forma estável e constante, para o cometimento de sucessivos crimes de gravidade considerável.

À vista do sobredito conceito legal, a organização criminosa deve revelar perfeita integração entre seus componentes, que interagem, em unidade de desígnios, no propósito de praticar determinados ilícitos, atuando com divisão de tarefas e observando escalonamento interno.

Deve haver, desse modo, relação de subordinação entre os criminosos.

Em situação oposta, ter-se-á mera "associação criminosa", antiga quadrilha ou bando, figura delitiva prevista no artigo 288 do Código Penal, pois, a despeito do agrupamento de indivíduos com propósito criminoso e vínculo associativo, ainda presentes as características de estabilidade e permanência, ausente estará a organização estruturante como elemento indispensável à configuração da figura delitiva prevista no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13.

E, diante do conjunto probatório amalhado nos autos, não se evidenciou, de forma concreta, que os acusados agiram no âmbito de uma organização criminosa, eis que ausentes elementos indicativos de que os envolvidos efetivamente se estruturaram em grupo hierarquicamente organizado para o fim de cometer crimes de receptação.

Tanto assim é que não se teve notícia de quem exercia a liderança ou comando do grupo, decorrência lógica da ausência de informações concretas e mais precisas sobre o funcionamento da suposta organização.

Assim, com a devida vênia do entendimento explicitado pelo Ministério Público, o contexto probatório apresenta-se, in casu, insuficiente para se reputar configurada a "organização criminosa", infração mais complexa e de maior gravidade que a "associação criminosa", esta, sim, evidenciada nos autos.

No entanto, há prova mais do que satisfatória para a condenação dos acusados (exceto ALINE) pelo crime previsto no artigo 288 do Código Penal, como se observará a seguir, sendo desnecessário o procedimento estabelecido no artigo 384 do Código de Processo Penal, pois a descrição fática contida na denúncia é coincidente e adequada para o imediato julgamento.

Na hipótese dos autos, os réus foram presos em flagrante nas condições já descritas e devidamente comprovadas, e para além das prisões, as investigações tiveram suporte em outros elementos, especialmente a interceptação de conversas anteriormente realizadas por aplicativo de telefonia celular, onde foi possível constatar o envolvimento dos acusados (exceto ALINE) em diálogos no mínimo intrigantes, além de evidenciar o relacionamento recíproco.

As provas mostraram-se suficientes para comprovar a prática de crime de caráter permanente, com atuação em conjunto dos envolvidos de forma contínua, e não isolada, pois no caso em concreto, verificou-se nas conversas extraídas dos aparelhos de telefonia que os acusados (exceto ALINE), mantinham entre si contatos prévios, e estavam relacionados, em maior ou menor grau, com ações de receptação. Percebe-se a existência de conversas travadas entre FERNANDO (vulgo "Nando Gordão") e LUIZ PAULO (fls. 2043) onde tratam de questão atinente a um caminhão. Além disso, o número do telefone de "Nando" constava da agenda de FRANCISCO, como se observa de fl. 2045. Diversas conversas de ALDO revelam seu envolvimento profundo com ações de crimes patrimoniais, como se observa dos registros de fls. 2049. Ademais, ALDO e FERNANDO, além de terem ido juntos ao local dos fatos, mantinham diálogos relacionados a roubo de carga, conforme se percebe à fl. 2054.

Portanto, não há como negar que os quatro envolvidos, além de terem praticado no dia 07 de janeiro de 2020 o crime de receptação qualificada, estavam associados, de forma permanente, para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais.

Inclusive, há notícia de investigações em andamento contra os acusados FERNANDO, LUIZ PAULO e LUCIANO por fatos criminosos relacionados a combustíveis, elemento que, embora, por si só, não seja suficiente para prova o ilícito, não pode ser ignorado ao menos como um fator indiciário.

Pessoas desvinculadas não se uniriam aleatoriamente em uma ação criminosa extremamente complexa, como a que se constata nos autos, e entender o contrário representaria, no mínimo, desatenção a uma realidade que se impõe.

É certo que sempre será possível alegar a insuficiência de provas, porém, a necessidade de se fundamentar as condenações criminais em provas seguras, não se confunde com o verdadeiro "fetiche" de se exigir infinitamente provas e mais provas, o que certamente inviabilizaria qualquer condenação criminal.

Assim, resta demonstrada a realização das condutas descritas nos artigos 180, § 1º, e 288, ambos do Código Penal.

Passo às dosimetrias das penas.

RÉUS ALDO E FERNANDO

As circunstâncias judiciais são favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base do delito do artigo 180, §1º, do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e do delito do artigo 288 do Código Penal, em 1 (um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição das penas, fixo-as em definitivo em referidos patamares, que somadas, alcançam 4 (quatro) anos de reclusão, para cada réu, além de 10 dias-multa.

O valor do dia multa é fixado em 1/5 do salário mínimo porque a atividade constatada nos autos revela-se altamente lucrativa.

Outrossim, na forma do que prevê o artigo 44 do Código Penal, entendo que os réus ALDO e FERNANDO fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que, no caso sub judice, tal medida parece ser socialmente recomendável.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços e prestação pecuniária de 10 salários mínimos, cada um, na forma do previsto nos artigos 45 e 46 do Código Penal.

Ficam os réus ALDO e FERNANDO condenados ao cumprimento de 4 anos de prestação de serviços à entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou outro estabelecimento congênere, inseridos em programas comunitário ou estatais, entidade esta que será indicada pelo Juízo da Execução.

Ficam condenados, também, ao pagamento de 10 salários mínimos em favor de instituição beneficente a ser indicada pelo Juízo da Execução. O valor da prestação pecuniária mostra-se adequado e pertinente, considerando o grau de envolvimento dos acusados com atividade ilícita bastante lucrativa - desvio de combustíveis, a revelar capacidade financeira.

Em caso de conversão das penas restritivas de direitos ora impostas, a pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto.

RÉU FRANCISCO

Como se observa das certidões de fls. 705, o réu FRANCISCO ostenta condenação por fato anterior (autos n. 0007842-27.2012.8.26.0320 - tráfico de drogas), mas com declaração de extinção da pena mais de cinco anos antes do fato (cumprimento ocorrido em 02.05.2014 e não em 06.10.2016), a revelar mau antecedente, devendo a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento 11 dias-multa para o crime do artigo 180, § 1º, do Código Penal, e 1 ano e 2 meses para o crime do artigo 288 do Código Penal.

Na segunda fase, sem agravantes ou atenuantes, não havendo reincidência, pois como já verificado, a extinção da pena nos autos n. 0007842-27.2012.8.26.0320 não ocorreu no ano de 2016, e sim em 02.04.2014, sendo possível verificar tal detalhe às fls. 705/706.

Ausentes causas de aumento ou redução das penas, fixo-as em definitivo nos patamares indicados, que somadas resultam em 4 anos e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

O regime inicial deve ser o semiaberto, inviável a substituição das penas por restritivas de direitos, seja pelo montante da somatória, superior a 4 anos, seja pelo mau antecedente.

O valor do dia multa é fixado em 1/5 do salário mínimo porque a atividade constatada nos autos revela-se altamente lucrativa.

RÉU LUIZ PAULO

Como se observa das certidões de fls. 731, o réu LUIZ PAULO ostenta condenação por fato anterior (autos n. 0008537-78.2012.8.26.0320 - crime de trânsito), mas com declaração de extinção da pena mais de cinco anos antes do fato que ora se apura, a revelar mau antecedente, devendo a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento 11 dias-multa para o crime do artigo 180, § 1º, do Código Penal, e 1 ano e 2 meses para o crime do artigo 288 do Código Penal.

Observo que a condenação pelo crime dos autos 0001235-90.2015.8.26.0320 não se presta a configurar reincidência ou maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial recente (porte de drogas para uso):

"O prévio apenamento do agente pela conduta de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) não constitui causa geradora de reincidência. Precedentes. 2. Uma vez que a acusada registra, em sua folha de antecedentes penais, apenas uma condenação anterior relativa à prática da conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, deve ser afastada a agravante da reincidência." (AgRg no REsp 1832209/SP - T6 Sexta Turma Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz J. 30.6.2020 Dje 4.8.2020).

"Conforme o entendimento firmado pela Sexta Turma no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP (Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 30/8/2018), revela-se desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, argumento que também se aplica para os maus antecedentes." (AgRg no HC 552355/SP - T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 10.3.2020 Dje 16.2020) "2. Em recente julgado deste Tribunal entendeu-se que "em face dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa geradora de reincidência" (REsp 1.672.654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

Presente a agravante decorrente da reincidência (0012371-60.2010.8.26.0320), observando-se, pela certidão de fl. 727/729, que a advertência acerca das condições do sursis foi promovida em 18.03.2013, a indicar que, ainda que o benefício tenha sido revogado indevidamente em data posterior, no melhor panorama a pena teria sido declarada extinta em 17.03.2015, ou seja, não haveria como se

evitar a reincidência. Elevo novamente as penas em 1/6, fixando-as em 4 anos e 1 mês de reclusão, além do pagamento 12 dias-multa, para o crime do artigo 180, § 1º, do Código Penal, e 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para o crime do artigo 288 do Código Penal.

Na derradeira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo-as definitivamente em 4 anos e 1 mês de reclusão, além do pagamento 12 dias-multa, para o crime do artigo 180, § 1º, do Código Penal, e 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão para o crime do artigo 288 do Código Penal

O regime inicial deve ser o